

1003384-67.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: José Luiz de Jesus Vieira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... casos de PERDA, EXTRAVIO, ROUBO, FURTO OU FRAUDE, quando a transação fora realizada mediante uso de senha (...) forçoso concluir pela inexistência de defeito na prestação do serviço, na medida em que para a Requerida, apresentados os documentos requeridos e exteriorizada a aceitação para realização da transação bancária, perfeita estava a celebração do negócio jurídico, tendo esta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

1ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433 - 5º andar, 5º andar - Sala 501, Penha de França - CEP 03634-010, Fone: 2093-6612r6004, São Paulo-SP - E-mail: penha1cv@tjsp.jus.br

C O N C L U S ã O

Em 05 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Penha de França, Comarca de São Paulo. José Luiz de Jesus Vieira, Juiz de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1003384-67.2022.8.26.0006 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Lincon Caldeira da Silva

Requerido:

Banco Digio S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira

Vistos.

LINCON CALDEIRA DA SILVA, ajuizou em 25/03/2022 "ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência" em face de BANCO DIGIO S.A., alegando, em síntese, que "(...) O autor relata que sofreu o chamado "sequestro relâmpago", tendo sido obrigado a fornecer a senha de seu cartão bancário aos criminosos que o mantinham sob ameaça com arma de fogo direcionada para sua cabeça, e assim que liberado contatou o banco para o bloqueio das operações. No entanto, para sua surpresa as movimentações no valor de R\$ 1.999,90, de R\$ 2.999,99 e de R\$ 68,00, no total de R\$ 5.657,89, não foram bloqueadas, mesmo fora do padrão de consumo do autor. Para não ter o nome negativado efetuou o parcelamento em 14/01/22 em 24 parcelas de R\$ 725,23, restando o pagamento de 22 parcelas no total de R\$ 15.955,06.

Requer "seja julgada procedente a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS, por ato da empresa Requerida determinando-se uma indenização pelos prejuízos causados tanto na esfera patrimonial (material), num valor de 2.612,74 valor em dobro a cobrança indevida, sem prejuízo dos acréscimos das parcelas vincendas eventualmente pagas, quanto na esfera extra

patrimonial (moral), cujo valor sugerido corresponde a um total de pelo menos 10 (dez) vezes o dano material já ocorrido, o que totaliza R\$ 13.063,70 (...)." Juntou documentos (fls.27/42).

Deferido ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita. Deferida a tutela de urgência (fls.45/47).

O requerido apresentou contestação (fls.62/73), alegando, preliminarmente a ilegitimidade passiva do réu; inépcia da petição inicial. Aduz que "(...) o cancelamento da compra deve ser efetuado diretamente pela Parte Autora com o estabelecimento comercial, conforme previsto no contrato de cartão de crédito (...) a responsabilidade pelo uso do plástico do cartão de crédito, bem como da proteção da senha pessoal referente a este, é obrigação do cliente, considerando que o mesmo encontra-se em sua posse desde o momento da contratação (...) o BANCO DIGIO não possui cobertura em casos de PERDA, EXTRAVIO, ROUBO, FURTO OU FRAUDE, quando a transação fora realizada mediante uso de senha (...) forçoso concluir pela inexistência de defeito na prestação do serviço, na medida em que para a Requerida, apresentados os documentos requeridos e exteriorizada a aceitação para realização da transação bancária, perfeita estava a celebração do negócio jurídico, tendo esta procedido como de praxe, não havendo, desta maneira, violação à qualquer dispositivo legal vigente. Desta forma, não há que se falar em responsabilidade do Réu pelos danos alegados (...)" Postula pela improcedência da ação.

Juntou documentos (fls.74/119).

Réplica (fls.128/133).

Juntou documentos (fls.134/137).

Instados a especificarem provas justificando a pertinência o autor se manifestou pela produção de prova oral; O banco se manifestou dizendo que cumpriu com a decisão da tutela de urgência e disse que não tem provas a produzir (fls.146/148).

É o relatório.

Decido.

Julgo o processo no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil/2015.

"Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discricão do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório." (STJ, 4ª Turma, REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos Carneiro, julgado em 21.08.90, DJU 17.09.90, p. 9.514).

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida porque se confunde com o mérito e com este será analisada.

Já a preliminar de "inépcia da inicial", também não merece ser acolhida, pois, ao contrário do alegado, o autor relatou os fatos com razoável clareza e formulou pedidos compatíveis com os fatos relatados, não excluídos a priori do ordenamento jurídico pátrio.

Os elementos de prova juntados aos autos, e especificamente o boletim de ocorrência (fls.27/31), não impugnado, é incontroversa a alegação de que houve crime de sequestro no qual o autor fora vítima, tendo sido mantido refém por criminosos que o obrigaram a entregar dados e documentos, realizando compras no cartão de crédito do autor.

As movimentações no valor de R\$ 1.999,90, de R\$ 2.999,99 e de R\$ 658,00, no total de R\$ 5.657,89, não foram bloqueadas (fl.36).

Com efeito, as movimentações acima revelam um nítido desvio de padrão de uso do autor da referida conta. Trata-se, portanto, de operações atípicas e que encontrariam óbice por meio de algoritmos de segurança utilizados pelo sistema

bancário, mas não encontraram impedimento no caso concreto.

Logo, houve nítida e abrupta mudança do perfil do correntista, e tal situação demandava análise pela equipe de segurança do banco, que poderia ter procedido ao bloqueio da conta out entado realizar contato com o autor para obter esclarecimentos, podendo ter evitado o desfecho danoso ou ao menos minimizado sua extensão.

É de se observar que a costumeira alegação de fraude de terceiro não tem o condão de escusar o prestador de serviço, na medida em que na atividade empresarial não se pode pretender apenas o bônus da mesma, senão também o inerente respectivo ônus, que deve ser suportado em virtude do risco da atividade, pelo que não se pode sequer excogitar da transferência de tal ônus ao consumidor, sob pena de se subverter a natureza da atividade empresarial, a condição do fornecedor e a hipossuficiência do consumidor, além do que, em princípio, a boa-fé se presume e a má-fé se comprova.

Aliás, o Banco tem todas as condições de demonstrar a segurança nos seus caixas eletrônicos e caixas pessoais, por meio de câmeras, para identificar os autores dos saques e movimentações outras inclusive, bem como em relação às que sejam feitas movimentações pela internet, mas prefere manter-se na cômoda posição de nada fazer nesse sentido, para depois imputar culpa aos clientes, numa escusa muito conveniente e que, por óbvio, não pode ser aceita. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Com efeito restaram frágeis as alegações do banco requerido sem produzir a prova impeditiva do direito da parte autora (artigo 341 do Código de Processo Civil/2015) esgotando-se em mero flatus vocis.

Ressalte-se que não pode o Banco réu simplesmente presumir, ainda que tacitamente, infalibilidade de seu sistema, e imputar culpa à parte autora, quando as regras de experiência (realidade empírica) demonstram o contrário em casos similares.

Nessa esteira, não tendo o réu comprovado fato impeditivo do direito da parte autora, por meio idôneo, que não a cômoda posição de se beneficiar de situação nebulosa, é de se reconhecer indevidas as movimentações financeiras efetuadas na conta corrente do autor, oriundos das movimentações financeiras objeto de fraude (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90).

Por outro lado, não há que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que diz "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável", na medida em que não se vislumbra má-fé do requerido em relação às movimentações financeiras na conta corrente do autor.

Com relação ao descumprimento da medida liminar o banco comprovou que não houve o descumprimento, pois houve estorno de valores a serem pagos em faturas a vencer, o qual totalizou em R\$ 11.406,24, restando apenas valores devidos e reconhecidos pela parte.

Nessa esteira, em que pesem os dissabores inerentes à situação de transações indevidas e falhas de serviço por parte da requerida, não há falar em dano moral, pois este somente se verifica quando há um fato de forma a causar não apenas um dissabor inerente ao contexto de desentendimentos e seus desdobramentos judiciais,

que é solucionado pela via judicial, mas sim quando ocorre um sofrimento acentuado, que extrapola o já inerente sofrimento atinente e aferível com base no homem médio, ou quando atinja honra objetiva ou subjetiva da pessoa, o que não é o caso dos autos.

Desta feita a procedência parcial da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a "ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência" ajuizada por LINCON CALDEIRA DA SILVA em face de BANCO DIGIO S.A., nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. TORNO definitiva a medida liminar concedida e DECLARO a nulidade dos saques objeto do litígio e, por consequência, DECLARO a nulidade das movimentações (transferências) que gerara os débitos nos valores de R\$ 1.999,90, de R\$ 2.999,99 e de R\$ 658,00, e, por consequência todo e qualquer encargo oriundos direta ou indiretamente de tais movimentações financeiras (fl.36) bem como o parcelamento realizado em 14/01/22 em 24 parcelas de R\$ 725,23; CONDENO o banco réu a ressarcir o autor dos respectivos valores indevidamente debitados, no montante de R\$ 5.657,89, devidamente atualizado pela Tabela do Tribunal de Justiça, desde o ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/81, artigo 1º, § 2º) e, a partir da citação, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, que remete ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

No mais, verifico que só a empresa requerida deverá suportar o ônus da sucumbência, pois o autor teve razão jurídica para o ajuizamento da ação, que foi o pleito principal acolhido, pelo que não se revela razoável que o não acolhimento de pleitos acessórios possam de alguma forma implicar ônus além do não acolhimento da parte acessória, o que deve ser considerado como sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, razão pela qual condeno a empresa ré ao pagamento das respectivas custas, despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de R\$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, e artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil/2015.

P.I.C.São Paulo, 05 de dezembro de 2022.